

1500153-05.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... via COPOM, sobre a prática do tráfico de drogas pelo local dos fatos. Que, também já tinha conhecimento, obtido por atividade em campo, sobre a prática do tráfico de drogas por parte do indiciado. Que, em razão disso, foi verificar a informação. Que, chegando no local, se deparou com o indiciado na via pública. Que, ele foi revistado e encontrado 05 porções de maconha em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500153-05.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500153-05.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

JOHN ADAM LUIZ DE ALMEIDA

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada John Adam Luiz de Almeida, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 120/123).

Determinou-se o processamento (fls. 131/133).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 168), apresentou resposta escrita (fls. 186/187). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 9 de setembro de 2022 (fls. 188/191) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 233).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 08/10 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 11 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 13/15) e definitivo (fls. 230/231 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Lucas Roberto Paneque, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "recebeu informação, via COPOM, talão informando que no local dos fatos havia um homem traficando drogas e que teria acabado de chegar drogas, não sendo informada o nome da pessoa. Contudo, o depoente já havia colhido diversas informações no sentido de que o indiciado estava traficando drogas. Que, foi verificar a informação e se deparou com o indiciado em frente a residência, tendo ele sido abordado e encontrado no bolso de sua bermuda cinco porções de maconha embaladas em sacos do tipo "juju". Que, nada mais de ilícito se encontrava com ele. Que, neste interim, saiu de dentro da residência a testemunha Jenifer e viu a abordagem policial, se assustando, trancando o portão da casa com o cadeado e se homiziando no interior da residência. Que, desconfiou da existência de drogas dentro da casa, sendo que o depoente chamou ela e atendeu a solicitação, abrindo o portão. Que, primeiramente questionou sobre a existência de drogas e Jenifer falou que nada havia lá. Que, foram realizadas buscas pela casa, sendo testemunha da por Jenifer e foi localizado dentro de uma caixa cheia de roupas, uma sacola de plástico com uma corda amarrada, escondido lá no meio, 55 porções de maconha, picadas no mesmo tamanho e envoltas com a mesma embalagem. Que, também foi localizado na mesma sacola R\$ 236,00 e sacos do tipo "juju" ainda sem utilização. Que, questionou a testemunha Jenifer e ela confirmou que seu amásio trafica droga há aproximadamente 60 dias, sendo que ele guarda a droga dentro da sacola e amarra a mesma na árvore dentro de outro terreno, próximo a residência dele. Que, a testemunha apontou a árvore e o depoente encontrou uma escada encostada. Que, também questionou o indiciado e ele confessou a prática do tráfico de drogas, dizendo que adquiriu na cidade de Olímpia 100 porções por R\$ 700,00 e estava vendendo a R\$ 10,00 cada, já vendido 40 porções. Que, em razão disso tudo, deu voz de prisão ao indiciado e o conduziu para a Delegacia de Polícia." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Luciano Roberto Franceschini, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "recebeu informação, via COPOM, sobre a prática do tráfico de drogas pelo local dos fatos. Que, também já tinha conhecimento, obtido por atividade em campo, sobre a prática do tráfico de drogas por parte do indiciado. Que, em razão disso, foi verificar a informação. Que, chegando no local, se deparou com o indiciado na via pública. Que, ele foi revistado e encontrado 05 porções de maconha em seu bolso. Que, enquanto estava abordando o indiciado, sua amásia saiu no quintal da casa, se assustou e trancou o portão com cadeado. Que, ela foi chamada e abriu o portão. Que, foi feita busca domiciliar, na presença da testemunha Jenifer e se encontrou, dentro de uma caixa com roupas, uma sacola plástica contendo 55 porções de maconha, R\$ 236,00 e alguns sacos do tipo "juju". Que, tanto as porções encontradas com o indiciado e localizadas em sua residência, eram do mesmo tamanho e estavam embaladas com o mesmo tipo de material. Que, ambos foram questionados e confirmaram que o indiciado trafica drogas há cerca de dois meses. Que, foi dada voz de prisão do indiciado e conduzido para a Delegacia de Polícia." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 06).

Confirmou a prática criminosa.

Confessou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a comercializar drogas. Por dificuldade financeira, decidiu fazê-lo. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

2.1.1 Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatrar; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio;

BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.^a edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo e guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Em relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento hospitalar (Santa Casa de Misericórdia local, no caso vertente) (art. 40, III, 1ª figura, da LD), dado que extraio das declarações dos agentes de segurança pública (de dois a três quarteirões [quadras], aproximadamente).

A configuração da causa de aumento de pena descrita no art. 40, III, da LD, que tem por circunstância as imediações de locais especialmente protegidos, não depende da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades (STJ - Quinta Turma - AgRg no HC n. 583.833-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item IV da ementa]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501944-97.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Estância Turística de Comarca de Olímpia - Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.U., j. 12/01/2021, p. 07 [índole objetiva]).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP -

15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 15/17), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado

pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

Nos termos do art. 24, caput, do CP, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se."

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, ao comparar os bens salvo (dificuldade financeira [sic], de interesse particular) e sacrificado (saúde pública, de interesse da sociedade), este é de maior importância que aquele, o que afasta, pelo princípio da ponderação de bens, a "inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado" (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 04).

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas circunstanciado (art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 12/03/2021

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

0001570-29/2016

13/04/2016

15/07/2019

214

*

Reincidência

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas,

desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, “enxugadores de gelo”, pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 [“Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido.”]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04 [“A exasperação, calcada no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06

(Lei de Drogas), se deu mediante fundamentação concreta e idônea, com esteio em dados que exorbitam os limites inerentes ao tipo penal..."]; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500636-21.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a ELY AMIOKA, V.U., j. 22/06/2022, p. 12; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Em apertadíssima síntese, os vários julgados mencionados posicionam-se no mesmo sentido, isto é, a circunstância considerada observa o art. 59 do CP e o art. 42 da LD.

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas deve ser considerada (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Min. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ – Quinta Turma – Habeas Corpus 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501484-76.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 11/05/2022, p. 14; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 05/06; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 07; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10 [71,900g de maconha]; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500647-84.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, V.U., j. 05/07/2022, p. 12; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07 [cinquenta e três trouxinhas de Cannabis Sativa L]).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP) e cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada aquela circunstância com uma destas, fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento hospitalar (Santa Casa de Misericórdia local, no caso sob análise) (art. 40, III, 1ª figura, da LD), de modo que, nos termos do art. 40 da LD, fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/6 (um sexto), em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa.

A biografia criminal da parte ré impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501721-13.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de

Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 14/07/2021, p. 05).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.3.1 Da culpabilidade diferenciada

Não desconheço, registro inicialmente, a causa prevista no art. 40, III, da LD, que estabelece o lugar do cometimento da infração como causa de aumento de pena.

No caso dos autos, as condições geográficas e turísticas da Comarca (movimentação intensa de pessoas) justificam, no entender deste magistrado, a circunstância judicial considerada.

Trata-se de verdadeira aptidão atrativa (vis attractiva).

Explico.

Nos termos do art. 966, caput, do CC, "considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços."

"Quando alguém com vocação para essa atividade identifica a chance de lucrar, atendendo à demanda de quantidade considerável de pessoas, na tentativa de aproveitar tal oportunidade, ele deve estruturar uma organização que produza a mercadoria ou serviço correspondente, ou que os traga aos consumidores" (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 21ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 03).

"O tráfico de drogas é atividade organizada" (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1502584-95.2021.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA [Presidente da Seção de Direito Privado], V.U., j. 25/02/2022, p. 07).

O traficante, indubitavelmente, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação – art. 966, caput, do CC – de drogas (art. 1º, parágrafo único, da LD).

A ação – conceitualmente – é empresarial.

Trata-se, deveras, de atividade econômica ilícita.

Alguém duvida disso? Eu não...

Para a exata compreensão da culpabilidade diferenciada, esclareço, a parte ré, atendendo à demanda de quantidade considerável de pessoas em virtude das condições geográficas e turísticas da Comarca (vis attractiva), na tentativa de aproveitar tal oportunidade, identificou a chance de lucro fácil, o que representa dado inerente (constitutivo, essencial, intrínseco) ao tipo penal previsto no art. 33 da LD (STJ – 6ª Turma – Recurso em Habeas Corpus 146.316 – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI, V.U., j. 2021), com benefício pessoal, de um lado, e, de outro, malefício de outrem.

É, justamente, esse aproveitamento (beneficiamento, favorecimento) da indústria do turismo local, com reflexo nos Municípios da Comarca (Altair, Guaraci, Severínia,

Cajobi e Embaúba, sem deslembrar dos seus Distritos) e naqueles contíguos (Barretos, São José do Rio Preto e Catanduva), que se leva em conta.

Pondero.

O desenvolvimento econômico da Estância Turística de Olímpia é baseado preponderantemente, mas não exclusivamente, na indústria do turismo (setenta por cento, aproximadamente).

Pelo perfil econômico da Comarca, a parte ré poderia exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços lícitos (art. 170, parágrafo único, da CF).

Direcionou, todavia, a ação para a circulação de drogas.

Não se trata de invenção deste magistrado, mas, porque objetivamente envolvido nos casos com a presidência dos processos criminais, sinto e direciono os critérios legais para a realidade local (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002510-23.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020, p. 12).

A propósito, exemplifico, moradores dos Municípios de Guaraci (autos n. 1502975-84.2020.8.26.0400 e n. 1501438-87.2019.8.26.0400), Severínia (autos n. 1500443-06.2021.8.26.0400), Cajobi (autos n. 1500470-37.2020.8.26.0557) e São José do Rio Preto (autos n. 1501060-63.2021.8.26.0400) dirigiram-se à Estância Turística da Comarca justamente para adquirir drogas para comercializá-las em vossas cidades.

A testemunha Lucas Roberto Paneque declarou, em Juízo, que a parte ré, por ocasião da prisão em flagrante, confirmou que se dirigiu ao Município da Estância Turística de Olímpia-SP para adquirir drogas a fim de comercializá-las na cidade de Cajobi-SP, onde reside.

Nessa perspectiva, cito reportagem da Redação R11 News, publicada no dia 10 de setembro de 2019 (<https://r11news.com/noticias/9746/>), que, a considerar os dados do Estado de São Paulo, comensurou a relação do crime de tráfico ilícito de drogas com o perfil turístico da Comarca:

"E a migração da criminalidade para o interior do Estado fizeram disparar as ocorrências de flagrante por tráfico ilícito de drogas na cidade.

Nos últimos 10 (dez) anos, esse tipo de ocorrência registrou uma alta de 935% (novecentos e trinta e cinco por cento), saltando de 13 (treze) casos em 2008 para 131 (cento e trinta e um) em 2018.

No mesmo período, em todo o Estado de São Paulo, o número de flagrantes por tráfico passou de 24.493 (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e três) para 48.322 (quarenta e oito mil e trezentos e vinte e dois), alta de 93% (noventa e três por cento).

Com baixos índices de violência, o tráfico ilícito de drogas é o crime que mais mobiliza as Polícias Militar e Civil na cidade.

Em 10 (dez) anos, foram lavrados 2002 (dois mil e dois) flagrantes em Olímpia. Desse montante, 1090 (mil e noventa) casos foram de tráfico ilícito de drogas, o que representa 54% (cinquenta e quatro por cento) do total.

Em todo o Estado, os flagrantes por tráfico respondem por 36% (trinta e seis) dos autos lavrados em Delegacias.

A diferença pode ser explicada pelo perfil da cidade e pela atuação das forças policiais".

Respeitado entendimento diverso, concluo, a culpabilidade ponderada (art. 59, caput, do CP) – o beneficiamento (aproveitamento, favorecimento) da indústria do turismo local com reflexo nos Municípios da Comarca e naqueles contíguos, repiso –

e a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LD não são coincidentes (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500348-58.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/04/2020, p. 07).

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente e as circunstâncias não são favoráveis.

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 05).

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade), II (reincidência) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN – V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA – V.U., j. 22/05/2014; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO – V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 – Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 – Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos

Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia - V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP - Câmara Especial - Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 - Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos), I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena